

1501028-24.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... fatos processados nestes autos.

O tráfico não era, pois, praticado pelo réu de forma eventual e esporádica, mas rotineiramente - o que caracteriza sua dedicação ao crime. Aliás:

Tráfico de Drogas - Prova segura - Tráfico de drogas demonstrado - Confissão judicial corroborada pela prova oral - Condenação mantida - Dosimetria - Pena e regime fixados com acerto - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501028-24.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501028-24.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148324/2019 - DEL.POL.COTIA, 5360207 - DEL.POL.COTIA, 3619/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2148324 - DEL.POL.COTIA, 3619/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DE MELO BARBOSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

PAULO HENRIQUE DE MELO BARBOSA, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 20 de maio de 2019, por volta das 16h17min, na Rua Vigo, n.º 125, Parque Monjolo, nesta cidade e Comarca de Cotia, o réu guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (f. 71) e apresentou defesa prévia (f. 78-79).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 08 de outubro de 2019 (f. 80).

O réu foi citado, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 108). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 109).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 10-11, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse do acusado, bem como a quantia de R\$ 160,00.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 61-63), sendo que o resultado foi positivo para "maconha" e "cocaína", drogas de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, tem-se que o policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relata que estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistou um veículo Fiat/Fiorino branco estacionado lá, com um rapaz parado ao lado em atitude suspeita, demonstrando nervosismo quando viu a viatura. Dirigiu-se até o indivíduo, o qual jogou para debaixo do veículo uma pochete azul que estava em suas mãos. Revistou-o e não encontrou nada em seu poder; a pochete que foi jogada para debaixo do carro, porém, continha drogas em seu interior. E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria do policial de incriminar injustamente o acusado. Assim, seu depoimento merece credibilidade e é valioso para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas no depoimento do policial militar, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

Mesmo porque a quantidade de drogas encontrada é incompatível com o mero uso próprio, a variedade era ampla (dois tipos de entorpecentes) e o próprio réu afirmou que estava armazenando as substâncias para o tráfico.

Assim, tanto a materialidade do crime, quanto a autoria delitiva do delito de tráfico ilícito de entorpecentes decorrem do conjunto probatório.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, não se afigura possível a sua incidência.

Isso porque a finalidade da majorante é punir com maior rigor aqueles que se utilizam da aglomeração típica existente nas imediações de estabelecimentos de ensino para facilitar e ampliar a comercialização das drogas.

Confira-se, aliás, o enunciado n.º 41 da edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ, que assim dispõe: "A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 deve ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito".

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ vem entendendo que, uma vez não configurada a traficância em dia e horário típicos da aglomeração existente nos locais previstos no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, não há que se falar na

incidência da causa de aumento em tela. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (STJ, REsp n.º 1719792/MG, Sexta Turma, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018)

Ocorre que, no caso concreto, embora o delito tenha sido praticado pelo réu nas proximidades de um estabelecimento de ensino, o horário em que foi praticado o delito (próximo às 16h00min) não costuma ser momento de aglomeração de pessoas, pois é um horário intermediário que não coincide com a entrada ou saída de alunos, de acordo com o sistema de horários majoritariamente adotado no Brasil (das 07h00min às 11h00min ou 13h00min ou desse horário às 18h00min), o que decorre das regras comuns de experiência.

E embora a testemunha ouvida em Juízo tenha afirmado que há instituição de ensino perto do local, não narrou a existência de conglomerado de alunos no momento da prisão em flagrante.

Nesses termos, tem-se que, no momento do crime, não havia aglomeração de pessoas no local, em decorrência da existência de estabelecimento de ensino nas imediações, que faça incidir a causa de aumento pretendida. Inviável, pois, sua incidência. No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua

dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa. 25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu, embora seja tecnicamente primário, não preenche o último requisito, já que restou demonstrado nos autos que ele se dedica a atividades criminosas.

Ora, o acusado foi preso em flagrante delito pela prática do mesmo delito pouco tempo após os fatos processados nestes autos.

O tráfico não era, pois, praticado pelo réu de forma eventual e esporádica, mas rotineiramente - o que caracteriza sua dedicação ao crime. Aliás:

Tráfico de Drogas - Prova segura - Tráfico de drogas demonstrado - Confissão judicial corroborada pela prova oral - Condenação mantida - Dosimetria - Pena e regime fixados com acerto - Privilégio incabível - Acusado preso em flagrante 1 mês depois de ser solto em processo a que responde por igual crime - Considerável quantidade e variedade de drogas - Indícios de dedicação à atividade criminosa e de contar com a confiança dos criminosos - Recurso defensivo improvido. (TJSP, Apelação Criminal n.º 1502379-10.2021.8.26.0548, 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator André Carvalho e Silva de Almeida, julgado em 09/03/2022)

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, guardava e trazia consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu PAULO HENRIQUE DE MELO BARBOSA, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o réu não ostenta antecedentes criminais, nos termos do enunciado da Súmula n.º 444 do STJ.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, fixo a pena base em 05 anos de reclusão – e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática do crime. Contudo, tendo em vista o enunciado da súmula n.º 231 do STJ, do qual se

comunga entendimento, mantenho a pena acima estipulada, provisoriamente. Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo a reprimenda, agora definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão - e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Decreto, nesta oportunidade, a prisão preventiva do réu.

Para a sustentação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos, dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

Outrossim, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência - havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (CPP, art. 313).

Na hipótese em apreço, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que se trata de sentença condenatória. O caso envolve imputação de crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 anos de prisão. O periculum libertatis também se sobressai presente. Deveras, o agente foi beneficiado com a liberdade provisória, e foi preso pouco tempo depois pela prática, em tese, do mesmo delito (tráfico ilícito de entorpecentes), o que indica que tenta fazer do tráfico o seu meio de subsistência. Aliás, segundo consta, não tem trabalho formal, concluindo-se, assim, que há grande probabilidade de que torne a delinquir. Sendo assim, a segregação cautelar do réu é necessária para garantir a ordem pública.

Decreto, pois, a prisão preventiva do acusado. Expeça-se o mandado de prisão preventiva e a guia de execução provisória.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob

o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Cotia, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA